

1501567-59.2018.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Caça
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/09/2022
... se manifestou:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INViolÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501567-59.2018.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501567-59.2018.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Caça
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076594/2018 - DEL.POL.CRISTAIS PAULISTA, 1261458 - DEL.POL.CRISTAIS PAULISTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SANTA DE CASSIA ALVES OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

SANTA DE CASSIA ALVES OLIVEIRA foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 29, inciso III, e artigo 32, caput, ambos da Lei nº 9.605/98, porque, segundo a acusação, no dia 5 de junho de 2018, na Rua Coronel Francisco Martins, nº 2997, da cidade de Cristais Paulista, comarca de Franca, tinha em cativeiro 1 (um) pássaro da fauna nativa brasileira, a saber, da espécie periquitão-maracanã (Psittacara leucophtalma), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como praticava contra o referido animal, ato de maus-tratos.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 1 usque 63).

Foi oferecida proposta de transação penal acusada, mas, embora devidamente

intimada, não compareceu à audiência. (fls. 72).

Citada (fls. 85), a acusada apresentou defesa prévia (fls. 90).

A denúncia foi recebida em 8 de janeiro de 2020 (fls. 91).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. Na dosimetria, destacou a aplicação a pena no mínimo legal. Suscitou pela fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Por fim, ressaltou a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, a princípio, ressaltou que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Ressaltou que se deve ter cautela ao se tomar como prova os depoimentos dos policiais. Requereu a absolvição da acusada por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Discorreu sobre a dosimetria e regime de aplicação de pena. Pugnou pela substituição da pena por restritiva de direitos e fixação de regime aberto.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo nulidades, nem imperfeições a serem corrigidas, passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva é improcedente.

Busca-se comprovar a materialidade delitiva pelo no boletim de ocorrência (fls. 2/3), pelo boletim de ocorrência ambiental (fls. 4/9), bem como pela prova testemunhal.

E a autoria do crime se fundamenta em prova ilícita, eis que não comprovada a autorização da acusada para ingresso dos agentes estatais em sua residência, bem como não comprovada a situação de flagrância anterior que justificasse a entrada forçada no local. Vejamos:

O policial militar Tiago Henrique disse se recordar vagamente da ocorrência. Houve informação de maus tratos e foram ao local averiguar, notando que o pássaro da fauna silvestre estava sob a posse da ré.

A acusada Santa Cássia, interrogada em juízo, disse que realmente tem o pássaro em questão. Ganhou o animal há algum tempo e cuidava muito bem da maritaca. A polícia adentrou o local sem autorização nenhuma, inclusive porque não havia nenhuma pessoa na residência.

Verifica-se que o ingresso na residência, segundo novel entendimento da jurisprudência superior, não atende à exigência legal.

Ora, ao cabo da instrução, não restou comprovada a autorização, da acusada ou de qualquer morador da residência para ingresso no local. A ré afirmou que não estava na residência e não autorizou a entrada dos policiais. O Boletim de Ocorrência confirmou a informação da acusada, constando que os policiais ingressaram na residência vizinha (com autorização da moradora) e pularam o muro para adentrarem

ao quintal da casa da ré e retirarem a ave (fls. 12).

Desse modo, não havendo dúvidas de que não houve autorização da acusada para ingresso em sua residência, há que ser declarada a ilicitude da prova obtida, sendo de rigor a absolvição da ré.

Nesse sentido, aliás, o julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral conhecida, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (grifamos)

Seguindo esse entendimento, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça, alterando posicionamento anterior sobre a matéria, se manifestou:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação amiúde irreversível de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que

pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (...) ((HC 628.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) (grifamos)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). [...] (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)

De igual modo, o Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou:

Tráfico de drogas - Ilícitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante - Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado - Ausência de fundadas razões - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA DEFESA PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501865-92.2019.8.26.0559; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021) (grifamos)

Assim, diante dos recentes entendimentos dos tribunais superiores no sentido de que o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio não pode ser afastado sem cuidado, sem controle judicial, por meras suspeitas dos policiais ou por denúncias anônimas, sendo necessário uma investigação prévia ou a comprovação, sem sombra de dúvidas, da autorização de entrada pelo morador da residência, de rigor a absolvição da ré.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e absolvo SANTA DE CASSIA ALVES OLIVEIRA da infração do artigo 29, inciso

III, e artigo 32, caput, ambos da Lei nº 9.605/98, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Franca, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA